

1502255-17.2022.8.26.0540
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Roubo
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Registro: 06/07/2022).

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) -
APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE
DESCCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS -
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS
DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502255-17.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502255-17.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDRÉ FIDELIS CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ANDRÉ FIDÉLIS CARDOSO foi denunciado por incursão no parágrafo 1º e no inciso IV do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 18 de novembro de 2022, por volta das 20h30min, no cruzamento da Avenida Itapark, 3468 - Jardim Itapark, na comarca de Mauá, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, em período noturno, subtraíram, em proveito comum, a motocicleta YAMAHA/MT03, placa GDU9C901, avaliada em R\$ 21.500,00, conforme auto de exibição, apreensão e avaliação à fl. 19, pertencente a Clayton De Moura.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl.103) e apresentou resposta à acusação (fls.104-5).

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a absolvição ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão e a exclusão da causa de aumento do repouso noturno, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 11-5), auto de reconhecimento de objeto (fl. 08), auto de exibição, apreensão e avaliação (fl. 19) e prova oral colhida.
A autoria é certa.

Interrogado, em solo policial (fl. 10), o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, manifestou-se (mídia digital).

A testemunha Wendrew, na fase administrativa (fls. 06-7), disse que: (sic) "trabalha como motoboy e que, eventualmente, presta serviços para a 'Padaria De Paula', situada na Avenida Itapark, 3.468, Jardim Itapark, nesta cidade, de propriedade de Clayton De Moura. Nesta noite, por volta das 20h30, passava em frente à referida padaria, quando viu um indivíduo empurrando a motocicleta Yamaha/MT-03, placa GDU-9C90, a qual se encontrava estacionada em frente à aludida padaria; o referido indivíduo estava acompanhado de 2 (dois) outros indivíduos, que estavam em motocicletas. Sienta que chegou a se aproximar deles, justamente por suspeitar que a referida motocicleta estava sendo subtraída; no entanto, neste momento, um dos indivíduos fez menção de estar armado, colocando a mão na cintura, e lhe disse: 'saí fora, nem tenta'. Neste momento, temendo por sua vida, o declarante se afastou deles; em seguida, entrou na padaria e comunicou que a motocicleta havia sido subtraída. Logo em seguida, viu quando motocicletas da Rocam passaram próximo a ele e tomou o mesmo sentido para o qual se dirigiam os referidos policiais militares; quando os alcançou, eles já haviam abordado um dos indivíduos que estavam empenhados na subtração da motocicleta Yamaha/MT-03, placa GDU-9C90, sendo especificamente aquele que a empurrava, que foi saber se tratar de André Fidélis Cardoso. Sienta que, embora não tenha visto a face do referido indivíduo quando presenciou a subtração, conseguiu reparar no capacete que ele utilizava, de cor preta, viseira transparente, sem proteção no queixo e com um adesivo na parte de trás; este era exatamente o capacete que André Fidélis Cardoso utilizava durante a abordagem dos policiais militares. Reconhece, pois, sem sombra de dúvidas, o capacete que lhe é apresentado nesta oportunidade como sendo aquele utilizado por André Fidélis Cardoso tanto no momento da subtração da motocicleta Yamaha/MT-03, placa GDU-9C90, como, também, no momento em que era abordado pelos policiais militares (...)"

Em juízo, disse que parou no farol e viu três rapazes em duas motos, ao lado da moto de Clayton, seu conhecido. Retornou e viu que os rapazes já estavam saindo com a moto de Clayton, um deles empurrava a moto furtada e os outros dois estavam nas outras duas motos. Entrou na padaria e avisou Clayton (mídia digital).

O policial militar Kaio, na fase administrativa (fls.03-4), historiou que: (sic) "estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, qual seja Rua Antenor Nincão, em

frente ao numeral 22, Jardim Itapark, nesta cidade de Mauá/SP, quando se depararam com 3 (três) motocicletas, cada uma delas ocupada por um indivíduo. Logo que avistaram as motocicletas da ROCAM, os referidos indivíduos aceleraram a fim de se evadir dos policiais militares; dois deles lograram efetivamente se evadir, de modo que não foram identificados, tampouco foi possível tomar nota das placas das respectivas motocicletas. No entanto, o ocupante da motocicleta Yamaha/MT-03, placa GDU-9C90, dela desembarcou e a abandonou deitada no chão, tentando, em seguida, se evadir a pé, sendo, em seguida, abordado pelos policiais militares. Foi, então, identificado como sendo André Fidélis Cardoso. A referida motocicleta estava com o miolo da chave danificado, o que chamou a atenção para a possibilidade de se tratar de produto de alguma forma de ilícito criminal; feitas as pertinentes pesquisas, estas não indicaram qualquer irregularidade em relação à referida motocicleta. Entretanto, um outro motociclista que presenciou a abordagem se aproximou dos policiais militares e lhes informou que conhecia o dono da referida motocicleta, qual seja Clayton De Moura, proprietário de uma padaria, 'Padaria De Paula', localizada próxima ao local dos fatos, na Avenida Itapark, 3.468, Jardim Itapark, também nesta cidade; informou, outrossim, que a referida motocicleta havia acabado de ser furtada, bem como que havia feito contato com o referido proprietário, que estava se deslocando para o local. O referido motociclista não foi qualificado. Clayton De Moura, então, compareceu ao local da abordagem e, em conversa informal, reconheceu a motocicleta como sendo sua e confirmou que ela havia acabado de ser furtada; não havia tido tempo, ainda, de comunicar o fato ao COPOM, tampouco de elaborar boletim de ocorrência na Polícia Civil. (...) Em conversa informal, André Fidélis Cardoso inicialmente havia dito que os indivíduos que ocupavam as outras motocicletas o haviam obrigado a furtar a motocicleta Yamaha/MT-03, placa GDU-9C90; depois, mudou a versão e disse que os mesmos indivíduos lhe pagariam cerca de R\$ 200,00 (duzentos reais) para que levasse a motocicleta para um lugar situado na Zona Leste da capital".

No mesmo sentido o depoimento do policial Jurandir (fl.05).

Em juízo, o policial Jurandir disse que durante patrulhamento viram três motocicletas. Os condutores, ao perceberem a presença da equipe, tentaram fugir. O réu, piloto de uma delas, deitou a moto no chão, não conseguiu se evadir e foi abordado. O acusado apresentou diversas versões, primeiro disse que era vítima e tinha sido obrigado a furtar a moto, depois disse que ganharia R\$200,00 para levar a moto para a zona leste de São Paulo. Na sequência apareceu no local outro motociclista dizendo que conhecia o proprietário da moto furtada, que compareceu no local e afirmou que a sua moto tinha sido furtada em frente ao seu comércio, minutos antes (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Assim, a prova oral colhida autoriza o desate condenatório, tendo em vista que o

réu foi detido na posse da res furtiva, logo após a subtração, utilizando o mesmo capacete que o furtador utilizava no momento da subtração da moto. Nesse sentido:

Apelação. Furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Desclassificação para o crime de receptação simples. Insurgências ministerial e defensiva. Necessidade de condenação dos réus pelo crime de furto qualificado. Réus surpreendidos por policiais em poder de bicicleta subtraída momentos após o crime de furto. Delito consumado. Condenação. Cálculo das penas. Réu Márcio reincidente e possuidor de maus antecedentes. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0007500-40.2017.8.26.0126; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020 - grifo nosso)

A qualificadora do concurso de pessoas está devidamente comprovada diante da prova oral produzida.

Todavia, não deve incidir a causa de aumento do repouso noturno, em virtude do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (STJ, Tema Repetitivo 1087, RESp 1888756, RESp 1891007 e RESp 1890981).

Sobre o tema, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo manifestou-se:

JUIZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. NÃO APLICAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DO STJ. TEMA 1087/STJ. ACÓRDÃO REFORMADO. Consoante novel entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, fixada por meio de precedente dotado de força vinculante, "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (STJ, Terceira Seção, RESp. nos 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.891.007/RJ - tema 1087). Impossibilidade de valorar, em recurso exclusivo da defesa, o repouso noturno como circunstância judicial negativa, sob pena de indevida reformatio in pejus. V. acórdão de fls. 267/288 reformado para, afastada a majorante do repouso noturno, redimensionar as penas do réu Leandro da Silva Almeida para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa mínimos, dando-o como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, II (escalada) e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal; mantidos, no mais, a r. sentença e o v. acórdão recorrido. (TJSP; Apelação Criminal 1500070-83.2020.8.26.0537; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022 - grifo nosso).

FURTO QUALIFICADO - Art. 155, §§ 1º e 4º, c.c. art. 14, II, CP - Apelos ministerial e defensivo já julgados - Trânsito em julgado para o órgão acusatório - Recurso Especial interposto pela defesa - Determinação pela C. Presidência da Seção Criminal deste E. TJSP de nova análise por esta Câmara - Juízo de retratação, cf. art. 1030, II, CPC - Tese firmada pelo E. STJ, no Tema Repetitivo nº 1087, de que 'A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)' - Necessidade de afastamento da majorante - Adequação da pena - Descabimento de análise dos demais pleitos por meio deste - Recurso defensivo parcialmente provido (voto nº 46429). (TJSP; Apelação Criminal 1501423-15.2020.8.26.0617; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022 - grifo nosso).

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo uso de chave falsa, majorado pelo repouso noturno. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Prova segura. Qualificadora demonstrada pela prova oral e pericial. Condenação mantida. Dosimetria. Mantidos o aumento operado na primeira fase, pelos maus antecedentes e a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa. Causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno deve ser afastada. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.087 do STJ). Maus antecedentes e reincidência impõem o regime prisional fechado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1538267-79.2021.8.26.0050; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022 - grifo nosso).

Dessa forma, comprovado o furto qualificado pelo concurso de agentes.

Dosa-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, pena que torno definitiva à míngua de causas modificadoras.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante na posse da res furtiva minutos após sua subtração, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recurso de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessional para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um

princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque

Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da condenação. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de condenação, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de condenação colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decísium, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADES DAS DROGAS, LOCAL DO CRIME, APREENSÃO DE DINHEIRO, CONFISSÃO DO RECORRENTE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA DADAS AS CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL -

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO PISO. ADEQUADO O NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR PENA AQUÉM DO PISO – SÚMULA 231, DO C. STJ. – REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE – REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS – RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Criminal 1502209-62.2021.8.26.0540; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) g.N.

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

“Agravos regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

“A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal” (AgRG no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

“No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, "em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal", tendo o Magistrado pontuado que "a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação" (fl. 54).Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/03/2022).

Ainda assim, as penas não poderiam ser conduzidas aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O acusado, primário- as condenações mencionadas pela acusação não transitaram em julgado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, conforme art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do

parágrafo 2º, do citado dispositivo legal, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo a instituição beneficente, a ser indicada pelo juízo da execução.

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

Ante o exposto, julgo procedente a ação, para CONDENAR o réu ANDRÉ FIDÉLIS CARDOSO, qualificado nos autos, às penas de 02 anos de reclusão, sob regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade na forma acima especificada, e a pagar 10 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso IV do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito, nos termos dos artigos 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, os objetos apreendidos (fl.19) ficarão disponíveis para os interessados, desde que comprovada a propriedade, pelo prazo de 90 dias a contar da data do trânsito em julgado. Decorrido o prazo sem manifestação, fica determinado o perdimento do capacete, para posterior alienação em leilão ou destruição, se o caso. Em relação à motocicleta, intime-se o depositário (fl.20) para entrega dos bens ao 1º Distrito Policial de Mauá, no prazo de 30 dias, para que a autoridade policial providencie a restituição da motocicleta apreendida ao legítimo proprietário, mediante termo nos autos. Oficie-se comunicando.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA